

1502041-89.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... vários atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de drogas e agora se vê envolvido novamente com o tráfico de drogas a denotar um sério envolvimento com a criminalidade, evidenciam assim, a prática de mercancia ilícita.

Ressalto que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1502041-89.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502041-89.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VITOR AMBROSIO CANTARINO

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

JOSÉ VITOR AMBROSIO CANTARINO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 21hs, na Rua Benedito da Silva, nº 43, Mogi das Cruzes/SP, tinha em depósito e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 20 (vinte) invólucros contendo 18,16g de cocaína, substância entorpecente listada na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Recebida a denúncia (fls. 79/80) o réu foi regularmente citado (fls. 93) e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 111/112.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 136 e 147).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos

fatos narrados na denúncia.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 157/167, oportunidade em que, após tecer considerações acerca da prova produzida em Juízo, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.  
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 09/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, pelo laudo de constatação provisória de fls. 35/38, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 129/131, pelo laudo pericial de fls. 132/35, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado José Vitor Ambrosio Cantarino negou em Juízo a prática do delito de tráfico de drogas, informando que estava em frente à casa de seu tio para consumir drogas quando foi abordado pelos policiais. Disse que entregou as drogas aos policiais, os quais indagaram onde haveria mais, tendo ele então os levado até o hidrômetro, local em que guardou as drogas. Contou ter vendido alguns de seus bens pessoais para adquirir as drogas pagando por elas a quantia de cento e oitenta reais. Disse ser usuário de drogas desde a primeira passagem pela "Fundação Casa" pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

No caso em tela, as provas existentes sobejamente comprovam os fatos imputados.

Os policiais militares relataram em detalhes os fatos, não deixando dúvidas quanto à imputação irrogada contra o acusado.

O policial militar Jair Pinheiro da Silva Júnior contou que estava em patrulhamento de rotina visando atender ocorrência de perturbação do sossego quando avistou o acusado pelo retrovisor da viatura agachado próximo a um veículo mexendo em um hidrômetro, razão pela qual suspeitou tratar-se de furto de veículo que fez com que retornasse e efetuasse a abordagem. Disse que o acusado, ao ser abordado, entregou prontamente os entorpecentes que estavam com ele - cocaína-, porém, enquanto a policial que o acompanhava foi até o hidrômetro, o acusado empreendeu fuga sendo possível efetuar a prisão dele perto de outras pessoas três quarteirões distantes do local em que realizaram a primeira abordagem. Contou que algumas pessoas informaram que realmente o acusado tinha o costume de permanecer no local da primeira abordagem, embora desconhecesse que ali fosse um ponto de tráfico de drogas. Disse que retornaram ao local da primeira abordagem onde foi possível apreender quantidade maior de cocaína junto ao hidrômetro embaladas de forma idêntica a entregue por ele, além de certa quantia em dinheiro. Não se recorda se o acusado confessou estar traficando, e que aparentemente não tinha feito uso de drogas. Por fim, esclareceu que o tio dele reside em frente ao local da abordagem.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Cláudia da Fonseca, afirmando que o acusado teria confessado a prática do tráfico de drogas, alegando que morava em frente ao local da abordagem e que estava passando por situação difícil, embora

o tio dele que reside no local ter afirmado que ele não residia no local.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

“Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.” (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander).”

No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva:

“Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos.” (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022).

In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo réu não convence, sendo claro que sua narrativa possui mero caráter exculpatório, além de não encontrar ressonância nas provas carreadas aos autos.

Além do mais, os policiais militares foram firmes e seguros ao afirmarem o momento exato em que visualizaram o acusado mexendo em um hidrômetro, local em que posteriormente foram apreendidos os entorpecentes, além daqueles apreendidos em revista pessoal com ele.

Nesse sentido, o relato firme e convincente dos policiais militares, os quais merecem integral credibilidade, haja vista inexistir, nos autos, qualquer elemento de prova apto a infirmar sua força de convicção, observando-se que pequenas contradições são insitas à prova oral e não a maculam.

Não se olvida que, em casos como tais, os envolvidos são também usuários de drogas e, em geral, para sustentar o próprio consumo, passam a comercializar entorpecentes.

Ainda, não há como se crer na versão do acusado, que afirma que estava consumindo drogas na via pública e que guardou o restante em um hidrômetro. Versão unicamente destinada a eximir de tão grave imputação.

Destaco, ainda, que as provas são seguras nesse sentido e ficaram comprovadas, não só pela situação flagrancial retratada nos autos, a forma do acondicionamento de drogas prontas para venda, além da quantia em dinheiro guardada em um hidrômetro, aliado ao fato de que o acusado já responde a vários atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de drogas e agora se vê envolvido novamente com o tráfico de drogas a denotar um sério envolvimento com a criminalidade, evidenciam assim, a prática de mercancia ilícita.

Ressalto que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão.

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta que o acusado ostenta personalidade voltada para a prática de delitos, fixo a pena-base aumentada em um sexto, vale dizer, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse ponto, cumpre destacar a possibilidade de se utilizar registros anteriores na vara da infância e juventude para fins de verificação da personalidade dos agentes delitivos, na exata forma prescrita pelo art. 59 do Código Penal.

Veja o precedente do S.T.J.:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU QUE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. QUANTIDADE DA DROGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois registra a prática de ato infracional anterior equiparado ao crime de homicídio qualificado. Soma-se a isso, a quantidade de droga apreendida (1.077,93 de maconha e 14,32g de cocaína), além da balança de precisão. A prisão cautelar do recorrente está justificada, portanto, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A prática de ato infracional, embora não possa ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerada crime, pode ser sopesada na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Recurso improvido. (RHC 113.844/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)".

Na segunda fase de fixação da pena, reputo cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, de forma que reduzo a pena em um sexto, fixando-a no mínimo legal, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo previsto em lei, em observância a Súmula 231, do C. STJ.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos. De se notar o fato do acusado já ter respondido pela prática de vários atos infracionais, inclusive equiparado a tráfico de drogas (certidão de fls. 50/51e fls. 58).

Neste sentido:

“A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes” (AgRg no HC 546.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/10/2020)” (AgRg. no HC nº 650.867/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/4/21, DJe 16/4/21).

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes” (AgRg. no HC nº 635.905/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/3/21, DJe 19/3/21).

Não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, a justificar a redução da pena como se pode ver.

Cumprе trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico”.

No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas”.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo):

“O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios”.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP.

Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, preso em flagrante delito, permanece as circunstâncias que autorizaram a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação.

Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 56/60.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar JOSÉ VITOR AMBROSIO CANTARINO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade ao acusado, ante as razões expostas.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Por fim, determino a destruição do objeto apreendido, bem como a incineração dos entorpecentes, além do perdimento da quantia apreendida em favor da União.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2022.